

次の【事例】及び【判旨】に関する後記1から5までの各【記述】のうち、正しいものを2個選びなさい。

【事例】

甲は、自動車内でVにクロロホルムを吸引させて失神させた上、約2キロメートル離れた港までVを選び、自動車ごと海中に転落させて溺死させようという計画の下、Vにクロロホルムを吸引させた。甲は、Vが動かなくなったので、計画どおりVが失神したものと考え、港に運んで自動車ごと海中に転落させた。Vの遺体の司法解剖の結果、甲の計画とは異なり、Vは溺死ではなく、海中への転落前にクロロホルムの吸引により死亡していたことが判明した。

【判 旨】

甲の殺害計画は、クロロホルムを吸引させてVを失神させた上（以下「第1行為」という。）、その失神状態を利用してVを港まで運び、自動車ごと海中に転落させ（以下「第2行為」という。）、溺死させるというものであって、第1行為は第2行為を確実に容易に行うために必要不可欠なものであったといえること、第1行為に成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったと認められることや、第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性などに照らすと、第1行為は第2行為に密接な行為であり、甲が第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。

【記 述】

1. ダンプカーに女性を引きずり込んで数キロメートル離れた人気のない場所まで連れて行き性交しようという計画の下、抵抗する女性をダンプカーに引きずり込んだ上、計画どおり性交したが、引きずり込もうとした段階で加えた暴行により同女が負傷したという事例において不同意性交等致傷罪の成立を認める見解は、実行の着手時期に関してこの判旨の考え方と矛盾する。(改)
2. この判旨は、甲がVにクロロホルムを吸引させた場所と殺害計画を実行しようとしていた港との距離が約2キロメートルの距離にあったということを、実行の着手時期を決する上で考慮している。
3. この判旨が第1行為を開始した時点で殺人罪の実行の着手を認めたのは、第1行為自体によってVの死の結果が生じることを甲が認識・認容していたことを前提としている。
4. この判旨の立場に立てば、甲が第1行為によってVが死亡していることに気づき、自動車ごとVを海中に転落させる行為に及ばなかった場合でも、甲に殺人既遂罪が成立する。
5. この判旨の立場に立てば、第1行為を行ってもそれ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存在していたような場合には、甲に殺人未遂罪と重過失致死罪が成立することになる。

【素材】

最決平 16.3.22（百選 I 64 事件）

【事案】

実行犯3名は、自分達が乗った自動車をVの運転する自動車に追突させ、示談交渉を装ってVを自車の助手席に誘い込み、クロロホルムを使ってVを失神させ、さらに、Vを約2キロ離れた港まで運んで海中に転落させてでき死させるという計画を指示された。そして、指示された計画通り自分達の乗った自動車をVの乗った自動車に追突させた上、示談交渉を装ってVを自車の助手席に誘い入れ、多量のクロロホルムを染み込ませてあるタオルをVの背後から鼻口部に押し当て、クロロホルムの吸引を続けさせてVを昏倒させ（第1行為）、その後Vを約2キロ離れた港まで運び、Vを岸壁から海中に転落させて沈めた（第2行為）。しかし、Vは第2行為の前の時点で、第1行為により死亡していた可能性がある。

【判旨】

実行犯3名の殺害計画は、クロロホルムを吸引させてVを失神させた上、その失神状態を利用して、Vを港まで運び自動車ごと海中に転落させてでき死させるというものであって、第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであったといえること、第1行為に成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったと認められることや、第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性などに照らすと、第1行為は第2行為に密接な行為であり、実行犯3名が第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。

【コメント】

本決定は、実行犯の殺害計画の内容も判断資料に加えた上で、①実行犯の殺害計画において、第1行為が第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠であったこと、②第1行為に成功すれば、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったこと、③第1行為と第2行為の間には時間的場所的近接性があるといえることなどの事情を重視して、第1行為を開始した時点で殺人罪の実行の着手があったと認められるとしたものである。

1 誤っている

最決昭 45.7.28（百選 I 62 事件）。本記述では、ダンプカーに女性を引きずり込んで数キロメートル離れた人気のない場所まで連れて行き性交しようという計画の下、抵抗する女性をダンプカーに引きずり込んだ上、計画どおり性交したが、引きずり込もうとした段階で加えた暴行により同女が負傷したという事案において不同意性交等致傷罪を認める見解が、実行の着手時期に関する判旨の考え方と矛盾するかが問題となる。本記述の見解は、犯人の計画を考慮した上でダンプカーに女性を引きずり込んだ段階で不同意性交等罪の実行の着手を認めるものである。なぜなら、この見解は、犯人の計画を考慮した上で、不同意性交に接した行為であるからこそ実行の着手を認めるものであり、仮に、被告人らが被害者をダンプカーでどこかの家に連れて行き、そこで不同意性交するつもりであったときは、ダンプカーに引きずり込む暴行は実行の着手とはいえないと思われるからである。【判旨】は、実行犯の殺害計画の内容も判断資料に加えた上で、①実行犯の殺害計画に

において、第1行為が第2行為を確実にかつ容易に行うために必要不可欠であったこと、②第1行為に成功すれば、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったこと、③第1行為と第2行為との間には時間的場所的近接性があるといえることなどの事情を重視して、第1行為を開始した時点で殺人罪の実行の着手があったと認められるとしたものである。よって、本記述の見解は実行の着手の時期を判断する上で、犯人の計画を考慮する点で判旨と矛盾しない。以上より、設問の見解は、実行の着手時期に関してこの判旨の考え方と矛盾しない。

2 正しい

最決平 16.3.22 (百選 I 64 事件)。本記述では、判旨が甲がVにクロロホルムを吸引させた場所と殺害計画を実行しようとしていた港との距離が約2キロメートルの距離にあったということを、実行の着手時期を決する上で考慮しているかが問題となる。【判旨】は、実行犯の殺害計画の内容も判断資料に加えた上で、①実行犯の殺害計画において、第1行為が第2行為を確実にかつ容易に行うために必要不可欠であったこと、②第1行為に成功すれば、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったこと、③第1行為と第2行為との間には時間的場所的近接性があるといえることなどの事情を重視して、第1行為を開始した時点で殺人罪の実行の着手があったと認められるとしたものである。そして、甲がVにクロロホルムを吸引させた場所と殺害計画を実行しようとしていた港との距離が約2キロメートルの距離にあったということは、自動車での移動という点にかんがみれば第1行為と第2行為との時間的場所的接着性を肯定する上で考慮されたとされている。よって、甲がVにクロロホルムを吸引させた場所と殺害計画を実行しようとしていた港との距離が約2キロメートルの距離にあったということを、実行の着手時期を決する上で考慮しているといえる。

3 誤っている

最決平 16.3.22 (百選 I 64 事件)。本記述では、判旨が第1行為を開始した時点で殺人罪の実行の着手を認めたのは、第1行為自体によってVの死の結果が生じることを甲が認識・認容していたことを前提としているかが問題となる。【事例】では、「甲は、自動車内でVにクロロホルムを吸引させて失神させた上、約2キロメートル離れた港までVを運び、自動車ごと海中に転落させて溺死させようという計画の下、Vにクロロホルムを吸引させた。」としている。甲は第1行為自体によってVを失神させようとしたにすぎないため、判旨において、第1行為自体によってVの死の結果が生じることを甲が認識・認容していることを前提としていない。よって、判旨は第1行為自体によってVの死の結果が生じることを甲が認識・認容していたことを前提とはしていない。

4 正しい

最決平 16.3.22 (百選 I 64 事件)。本記述では、判旨の立場に立てば、甲が第1行為によってVが死亡していることに気づき、自動車ごとVを海中に転落させる行為に及ばなかった場合でも、甲に殺人既遂罪が成立するかが問題となる。【判旨】は、「甲が第1行為を開始した時点で…殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当である。」としており、第1行為を開始した時点で殺人罪の実行の着手を認めている。そして、Vが「海中への転落前にクロロホルムの吸引により死亡していた」ことから、第1行為とVの死亡の結果との間には因果関係が認められる。更に、クロロホルムを吸引させて被害者を失神させた上自動車ごと海中に転落させるという一連の殺人行為に着手して、その目的を遂げた場合には、犯人の認識と異なり、海中に転落させる前の時点でクロロホルムを吸引させる行為により被害者が死亡していたとしても、第1行為を開始した時点で、一連の殺人行為により被害者を殺害する意思を有していることから、甲には第1行為の時点で殺人の故意が認められる。よって、判旨の立場に立つと、甲が第1行為によってVが死亡していることに気づき、自動車ごとVを海中に転落させる行為に及ばなかった場合でも、甲に殺人既遂罪が成立する。

5 誤っている

最決平 16.3.22 (百選 I 64 事件)。本記述では、判旨の立場に立てば、第1行為を行ってもそれ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存在していたような場合には、甲に殺人未遂罪と重過失致死罪が成立するかが問題となる。【判旨】は、①実行犯の殺害計画において、第1行為が第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠であったこと、②第1行為に成功すれば、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったこと、③第1行為と第2行為との間には時間的場所的近接性があるといえることなどの事情を重視して、第1行為を開始した時点で死の結果発生の客観的な危険性が認められるので、殺人罪の実行の着手があったと認められるとしている。この判旨の立場に立つと、第1行為を行ってもそれ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存在していたような場合には、死の結果発生の客観的な危険性が認められないので、第1行為の開始の時点で殺人罪の実行の着手は認められない。この場合の罪責は、第1行為は人に対する不法な有形力の行使であって暴行罪に該当し、それによって死亡の結果が生じているので、傷害致死罪(205条)が成立する。よって、甲に殺人未遂罪と重過失致死罪が成立するとはいえない。